

[Anmerkung Bearbeiter/in: Namen und Firmen, Rechtsformen und Produktbezeichnungen, Adressen (inkl. URLs, IP- und E-Mail-Adressen), Aktenzahlen (und dergleichen), etc., sowie deren Initialen und Abkürzungen können aus Pseudonymisierungsgründen abgekürzt und/oder verändert sein. Offenkundige Rechtschreib-, Grammatik- und Satzzeichenfehler wurden korrigiert.]

## T E I L B E S C H E I D

### S P R U C H

Die Datenschutzbehörde entscheidet über die Datenschutzbeschwerde von Ulrich A\*\*\* (Beschwerdeführer), vertreten durch Dr. Hermann B\*\*\* Rechtsanwalts KG vom 15. Februar 2023 gegen die Landespolizeidirektion Oberösterreich (Beschwerdegegnerin) wegen Verletzung im Recht auf Geheimhaltung wie folgt:

- Der Beschwerde wird teilweise stattgegeben und es wird festgestellt, dass die Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführer in seinem Recht auf Geheimhaltung verletzt hat indem sie unrechtmäßig seine personenbezogenen Daten im Rahmen einer erkennungsdienstlichen Maßnahme am 12. Januar 2023 erhoben hat.

Rechtsgrundlagen: §§ 1, 33, 36, 38 und 45 des Datenschutzgesetzes – DSG, BGBl. I Nr. 165/1999 idgF; §§ 16 Abs. 2, 65, 73, 75 und 90 des Sicherheitspolizeigesetzes – SPG, BGBl. Nr. 566/1991 idgF.

### B E G R Ü N D U N G

#### A. Vorbringen der Parteien und Verfahrensgang

1. Der Beschwerdeführer brachte in seiner Eingabe vom 15. Februar 2023 an die Datenschutzbehörde im Wesentlichen vor, die Beschwerdegegnerin habe ihn dadurch in seinem Recht auf Geheimhaltung und im Recht auf Löschung verletzt, indem am 12. Januar 2023 die Organe der belangten Behörde den Beschwerdeführer einer gewaltsamen, erkennungsdienstlichen Behandlung durch die Abnahme von Fingerabdrücken, die Erhebung von Maße und die Herstellung von Fotos unterzogen haben.

Zusammengefasst sei der Beschwerdeführer mit dem falschen Vorwurf konfrontiert worden, er habe ein Postpaket unterschlagen, welches er bei der Poststelle neben einem Abgabeautomaten gefunden habe. Er habe sich zur Polizei begeben, um dort den Sachverhalt richtig wiederzugeben und habe versucht, eine Rechtsauskunft über den Finderlohn einzuholen, welche ihm die Beamten nicht haben geben können.

Der Beschwerdeführer habe am 13. Januar 2023 einen Löschantrag an den Beschwerdegegner gestellt, welchem der Beschwerdegegner mit Antwort vom 24. Januar 2023 nicht entsprochen habe.

2. Die Beschwerdegegnerin erwiderte mit Stellungnahme vom 6. März 2023 zusammengefasst, dass der Beschwerdeführer am 12. Januar 2023 von Beamten der Beschwerdegegnerin

erkenntnisdienlich behandelt, welche gegen den Beschwerdeführer als Beschuldigten wegen Verdacht der Unterschlagung gemäß § 134 StGB ermittelt haben. Der begründete Verdacht des Vorliegens und die Art der dem Beschwerdeführer zur Last gelegten strafbaren Handlung (Unterschlagung iSd § 134 StGB) habe die Durchführung einer erkenntnisdienlichen Maßnahme zum Zeitpunkt ihrer Vornahme gerechtfertigt.

Der Beschwerdeführer gehe in seiner Beschwerde nicht darauf ein, weswegen Beschwerdegegnerin sein Recht auf Geheimhaltung schutzwürdiger personenbezogener Daten verletzt habe. Die im Zusammenhang mit der gegenständlichen Amtshandlung zwangsläufig erfolgte Verarbeitung personenbezogener Daten des Beschwerdeführers sei gemäß § 74 Abs. 1 StPO gerechtfertigt bzw. zulässig. Eine Löschung dieser Daten erfolge von Amts wegen im Rahmen der geltenden Skartierungsvorschriften. Die Verarbeitung erkenntnisdienlicher Daten des Beschwerdeführers erfolge auf der Grundlage von § 65 SPG; eine Löschung erfolgt gemäß § 73 Abs. 1 Z. 4 SPG von Amts wegen, wenn der Tatverdacht weg falle (z.B. bei Einstellung des Verfahrens nach § 190 StPO durch die StA).

3. Mit Eingabe vom 13. April 2023 brachte der Beschwerdeführer im Wesentlichen vor, dass gegenständlich nicht eine dem Gesetz entsprechende Anlasstat vorliege, geschweige denn gäbe der vorliegende Sachverhalt eine Prognose her, dass ein weiterer „gefährlicher Angriff“ im Sinne des Gesetzes zu erwarten gewesen wäre. Darüber hinaus fehle es auch hier an einer ausreichenden Grundlage für die nach § 67 Abs. 1 SPG abzugebende Prognose. Der Beschwerdeführer monierte, dass die Voraussetzungen nach § 65 Abs. 1 und § 67 Abs. 1 SPG nicht vorgelegen haben und daher die Vornahme der erkenntnisdienlichen Behandlung rechtswidrig gewesen sei und damit dem Löschantrag hätte Folge gegeben werden müssen. Die Ausführungen der belangten Behörde orientieren weder an der Judikatur noch finden Sie Deckung im Gesetz.

4. Mit Eingabe vom 2. Mai 2023 übermittelte der Beschwerdeführer das Erkenntnis des oberösterreichischen Landesverwaltungsgerichts zur GZ: LVwG-780266/7/KLi/NF vom 21. April 2023.

5. Mit Eingabe vom 11. Mai 2023 brachte die Beschwerdegegnerin zusammengefasst vor, bezüglich der behaupteten Verletzung im Recht auf Löschung werde mitgeteilt, dass bei neuerlicher Beurteilung des Sachverhaltes insbesondere unter Berücksichtigung der Entscheidung des Landesverwaltungsgerichtes Oberösterreich dem Ansinnen des Beschwerdeführers im Sinne des § 24 Abs. 6 DSG entsprochen worden sei. Der Beschwerdeführer sei informiert worden.

6. Der Beschwerdeführer hat trotz entsprechender Aufforderung, kein weiteres Vorbringen innerhalb der Frist erstattet. Ein entsprechender Weiterleitungsbericht liegt dem Akt bei und es liegt keine Fehlermeldung eines E-Mail Servers vor.

7. Mit Erledigung vom 4. August 2023 stellte die Datenschutzbehörde das Verfahren hinsichtlich dem Recht auf Löschung gemäß § 24 Abs. 6 DSG ein und gewährte der Beschwerdegegnerin Parteigehör hinsichtlich dem Recht auf Geheimhaltung.

8. Mit Eingabe vom 7. August 2023 wiederholte die Beschwerdegegnerin im Wesentlichen ihr Vorbringen, dass mit Erkenntnis des Landesverwaltungsgerichts Oberösterreich vom 21.04.2023, GZ: LVwG-780266/7/KLi/NF die gegenständliche erkenntungsdienstliche Behandlung für rechtswidrig erklärt worden sei. In der Folge seien die erkenntungsdienstlichen Daten unverzüglich gelöscht worden und der Beschwerdeführer mit Schreiben vom 11. Mai 2023 von der erfolgten Löschung in Kenntnis gesetzt worden.

## B. Beschwerdegegenstand

Beschwerdegegenstand ist die Frage, ob die Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführer in seinem Recht auf Geheimhaltung verletzt hat, indem diese personenbezogenen Daten des Beschwerdeführers im Rahmen einer erkenntungsdienstlichen Maßnahme unrechtmäßig erhoben habe.

## C. Sachverhaltsfeststellungen

1. Am 7. Jänner 2023 hielt sich der Beschwerdeführer in der V\*\*\*-City auf. Beim dortigen Postamt in der Nähe der Postausgabeautomaten fand er ein Paket, dessen Eigentümer augenscheinlich nicht in der Nähe war. Der Beschwerdeführer gab dieses Paket zunächst beim Infoschalter der V\*\*\*-City ab. Kurze Zeit später holte er es von dort wieder ab und wollte es nach seinen eigenen Angaben zum Fundamt bringen, um dort auch einen Finderlohn zu erhalten.

2. Nach den Angaben des Beschwerdeführers habe er schon öfter keinen Finderlohn erhalten, weshalb er das Paket wieder an sich genommen habe, um sicherzustellen, dass er dieses Mal auch den ihm zustehenden Finderlohn erhalten würde. Der Beschwerdeführer nahm das Paket zunächst zu sich nach Hause. Er öffnete das Paket dort, um den Inhalt zu sichten. Nach seinen Angaben habe er dadurch den Wert des Fundes und den sich daraus zu errechnenden Finderlohn ermitteln wollen.

3. Schließlich begab sich der Beschwerdeführer am 9. Jänner 2023 gegen 14:00 Uhr zur Polizeiinspektion M\*\*\*gasse und machte dort die zu Punkt 1. und Punkt 2. wiedergegebenen Angaben. Er wurde von den einschreitenden Polizeibeamten aufgefordert, das Paket beim Fundamt des Magistrates Linz abzugeben. Darüber hinaus wurde er auf die rechtlichen Konsequenzen der Nichtabgabe (Fundunterschlagung gemäß § 134 StGB) hingewiesen. Dem Beschwerdeführer wurde auch erklärt, dass ihm nicht die Daten des Eigentümers genannt würden, sondern er seine Daten bekannt geben solle. Dies wurde vom Beschwerdeführer verweigert. Der Beschwerdeführer verließ sodann die Polizeiinspektion M\*\*\*gasse.

In weiterer Folge begab sich eine Polizeistreife um 14:35 Uhr zur Adresse des Beschwerdeführers. Dort wurde dem Beschwerdeführer das Paket abgenommen und dieses sichergestellt. Der Beschwerdeführer verweigerte Antworten auf die an ihn gerichteten Fragen.

Schließlich kam der Beschwerdeführer um 15:00 Uhr nochmals zur PI M\*\*\*gasse und verlangte dort eine Bestätigung und die Dienstnummern der einschreitenden Beamten. Um 16:00 Uhr wurde dem Beschwerdeführer ein Sicherstellungsprotokoll übergeben. Darüber hinaus wurde er über den Verdacht der Unterschlagung gemäß § 134 StGB befragt. Der Beschwerdeführer verweigerte seine Mitwirkung und forderte eine schriftliche Ladung.

4. Mit einer „Ladung des Beschuldigten im Ermittlungsverfahren“ vom 9. Jänner 2023 wurde der Beschwerdeführer für 12. Jänner 2023 von 14:00 Uhr bis voraussichtlich 16:00 Uhr zur Polizeiinspektion M\*\*\*gasse geladen. Als Gegenstand der Vernehmung wurde „Fundunterschlagung“ genannt. Darüber hinaus wurde der Beschwerdeführer darauf hingewiesen, dass es notwendig sei, dass er persönlich erscheine. Außerdem wurde dem Beschwerdeführer angekündigt, dass im Anschluss an die Vernehmung eine erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt wird.

5. Der Beschwerdeführer leistete dieser Ladung Folge. Er kam am 12. Jänner 2023 um 14:00 Uhr zur belangten Behörde, wo zunächst eine Beschuldigtenvernehmung durchgeführt wurde. Diese Vernehmung endete um 14:50 Uhr.

In weiterer Folge wurde eine erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt, bei welcher Fingerabdrücke, Maße und Fotos des Beschwerdeführers erhoben wurden, wobei sich der Beschwerdeführer zunächst weigerte, an dieser mitzuwirken. Dem Beschwerdeführer wurde angekündigt, dass diese erkennungsdienstliche Behandlung auch zwangsweise durchgeführt werden kann. Der Beschwerdeführer begab sich in weiterer Folge mit den einschreitenden Polizeibeamten in einem Polizeifahrzeug von der Polizeiinspektion M\*\*\*gasse zum Polizeianhaltezentrum in der Nietzschestraße 33, 4020 Linz. Der Beschwerdeführer erklärte zwar ausdrücklich, mit der erkennungsdienstlichen Behandlung nicht einverstanden zu sein, ließ diese aber nach Androhung von Zwangsgewalt zu.

6. Mit Erkenntnis vom 21. April 2023 zur GZ: LVwG-780266/7/KLi/NF, erklärte das Landesverwaltungsgericht OÖ die der Beschwerdegegnerin zurechenbaren Organen durchgeführte erkennungsdienstliche Behandlung des Beschwerdeführers für rechtswidrig.

7. Die gegenständlichen Daten des Beschwerdeführers, welche im Rahmen der erkennungsdienstlichen Behandlung vom 12. Jänner 2023 erhoben wurden, wurden durch die Beschwerdegegnerin gelöscht und der Beschwerdeführer am 11. Mai 2023 davon in Kenntnis gesetzt.

**Beweiswürdigung:** Die getroffenen Feststellungen ergeben sich aus den insoweit übereinstimmenden Eingaben der beiden Parteien und insbesondere aus dem Erkenntnis des LVwG OÖ vom 21. April 2023 zur GZ LVwG-780266/7/KLi/NF.

#### D. In rechtlicher Hinsicht folgt daraus:

##### 1. Zum Anwendungsbereich des 3. Hauptstücks des DSG

Im gegenständlichen Fall handelte es sich unstrittig um eine Datenverarbeitung gemäß § 36 Abs. 1 DSG durch einen Verantwortlichen des öffentlichen Bereichs, die zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten erfolgt.

Es finden daher die Bestimmungen des 3. Hauptstücks des DSG Anwendung.

##### 2. Zur datenschutzrechtlichen Rollenverteilung

Die Beschwerdegegnerin ist in ihrer Funktion als Sicherheitsbehörde I. Instanz (vgl. § 8 Z 6 SPG) für die Erhebung und Speicherung der hier relevanten erkennungsdienstlichen Daten des Beschwerdeführers zuständig und somit als datenschutzrechtlicher Verantwortlicher gemäß § 36 Abs. 2 Z 8 DSG zu qualifizieren.

Dies wurde seitens der Beschwerdegegnerin auch ausdrücklich bestätigt.

##### 3. Zur Zulässigkeit der ursprünglichen Ermittlung der erkennungsdienstlichen Daten des Beschwerdeführers nach § 65 Abs. 1 SPG

Gemäß der Verfassungsbestimmung des § 1 Abs. 1 DSG hat jedermann, insbesondere auch im Hinblick auf die Achtung seines Privat- und Familienlebens, Anspruch auf Geheimhaltung der ihn betreffenden personenbezogenen Daten, soweit ein schutzwürdiges Interesse daran besteht.

Zunächst ist zu überprüfen, ob die ursprüngliche Ermittlung der erkennungsdienstlichen Daten des Beschwerdeführers im Rahmen seiner Einvernahme am 12. Januar 2022 rechtmäßig war (vgl. § 45 Abs. 1 Z 2 DSG).

Gemäß § 38 DSG ist die Verarbeitung personenbezogener Daten, soweit sie nicht zur Wahrung lebenswichtiger Interessen einer Person erforderlich ist, nur rechtmäßig, soweit sie gesetzlich oder in unmittelbar anwendbaren Rechtsvorschriften, die innerstaatlich den Rang eines Gesetzes haben, vorgesehen und für die Erfüllung einer Aufgabe erforderlich und verhältnismäßig ist, die von der zuständigen Behörde zu den in § 36 Abs. 1 leg. cit. genannten Zwecken wahrgenommen wird.

Eine solche Rechtsgrundlage für die Ermittlung der erkennungsdienstlichen Daten findet sich in § 65 SPG.

Gemäß § 65 Abs. 1 SPG sind die Sicherheitsbehörden ermächtigt, einen Menschen, der im Verdacht steht, eine mit gerichtlicher Strafe bedrohte vorsätzliche Handlung begangen zu haben, erkennungsdienstlich zu behandeln, wenn er im Rahmen einer kriminellen Verbindung tätig wurde oder

dies wegen der Art oder Ausführung der Tat oder der Persönlichkeit des Betroffenen zur Vorbeugung gefährlicher Angriffe erforderlich scheint.

Die Zulässigkeit einer erkennungsdienstlichen Behandlung setzt somit zusätzlich zum Verdacht auf Begehung einer mit Strafe bedrohten Handlung voraus, dass der Verdächtige entweder im Rahmen einer kriminellen Verbindung tätig wurde oder sonst auf Grund der Art oder Ausführung der Tat oder der Persönlichkeit des Betroffenen die erkennungsdienstliche Behandlung zur Vorbeugung weiterer gefährlicher Angriffe erforderlich erscheinen lässt (vgl. das Erkenntnis des VwGH vom 31. Mai 2012, Zl. 2011/01/0276 sowie vom 18. Juni 2014, 2013/01/0134). Gerade dieser vorliegenden wahrscheinlichen Rückfallgefährdung muss durch die erkennungsdienstliche Maßnahme in geeigneter Weise entgegengewirkt werden können (vgl. *Thanner/Vogl*, Sicherheitspolizeigesetz<sup>2</sup>, 671).

Entscheidend ist, ob überhaupt eine aufgrund der Art oder Ausführung der Tat oder der Persönlichkeit des Betroffenen wahrscheinliche Tatbegehungswahrscheinlichkeit vorliegt. Es ist jedoch eine einzelfallbezogene Beurteilung notwendig, da sonst jedes Delikt abstrakt betrachtet eine Rückfallgefährdung wahrscheinlich erscheinen lässt und somit zu jedem Zeitpunkt eine erkennungsdienstliche Behandlung gerechtfertigt wäre (vgl. den Bescheid der DSB vom 20. Oktober 2017, GZ: DSB-D122.734/0005-DSB/2017).

Der Beschwerdeführer stand zum damaligen Zeitpunkt in Verdacht, eine Unterschlagung nach § 134 StGB begangen zu haben.

Die erste Voraussetzung, nämlich der Verdacht, eine mit gerichtlicher Strafe bedrohte vorsätzliche Handlung begangen zu haben, ist daher erfüllt. Ob der Bf tatsächlich eine Fundunterschlagung im Sinne hatte, wird für die weitere rechtliche Würdigung dahingestellt bleiben.

Der Verwaltungsgerichtshof vertritt in diesem Zusammenhang in ständiger Rechtsprechung, dass bereits eine abstrakte Form von Wahrscheinlichkeit, die an der verwirklichten Tat anknüpft, für die Annahme ausreicht, die erkennungsdienstliche Behandlung sei zur Vorbeugung weiterer gefährlicher Angriffe erforderlich (vgl. etwa die Erkenntnisse vom 18. Mai 2009, Zl. 2009/17/0053, und vom 3. Juli 2009, Zl. 2009/17/0070).

Ein gefährlicher Angriff ist nach § 16 Abs. 2 Z 1 SPG die Bedrohung eines Rechtsgutes durch die rechtswidrige Verwirklichung des Tatbestandes einer gerichtlich strafbaren Handlung, die vorsätzlich begangen und nicht bloß auf Verlangen eines Verletzten verfolgt wird, sofern es sich um einen Straftatbestand nach dem Strafgesetzbuch handelt.

Eine erkennungsdienstliche Behandlung ist aber nicht geboten, wenn „die bezeichneten Umstände bzw. die mögliche Rückfallsgefahr oder zu erwartende Aufklärungswahrscheinlichkeit“ nicht hinreichend erkennen lässt, weshalb – etwa aufgrund der Art oder Ausführung der Tat oder Persönlichkeit eines Bf – die belangte Behörde die erkennungsdienstliche Behandlung für notwendig

hält (vgl. VwGH 18.06.2014, 2013/01/0134; 20.03.2013, 2013/01/0006; 31.05.2012, 2011/01/0276; 19.04.2012, 2012/01/0011).

Wie bereits vom Landesverwaltungsgericht (Oberösterreich) zur GZ: LVwG-780266/7/KLi/NF vom 21. April 2023 ausgeführt, lässt sich allein aus der Ankündigung des Beschwerdeführers, schon in der Vergangenheit oft keinen Finderlohn erhalten zu haben und dies solle im vorliegenden Fall anders sein, noch nicht darauf schließen, dass der Beschwerdeführer auch ein Wiederholungs- und/oder Rückfallstäter sein könnte. Darüber hinaus hat sich der Beschwerdeführer aus freien Stücken zur Polizeiinspektion begeben, war der Beschwerdeführer der Beschwerdegegnerin auch amtsbekannt und konnte auch an seiner Adresse angetroffen werden. Daher gab es keine Anhaltspunkte, dass sich der Beschwerdeführer einer Mitwirkung an der Arbeit der belangten Behörde entziehen würde.

Aufgrund der Persönlichkeit des Beschwerdeführers und der Umstände der konkreten Tat war somit im Zeitpunkt der Erfassung der erkennungsdienstlichen Daten von einer äußerst geringen Wahrscheinlichkeit auszugehen, dass der Beschwerdeführer weitere gefährliche Angriffe begehen werde und sich der Verfolgung entziehen werde. Daher war eine Vorbeugung dieser Angriffe nicht erforderlich. Folglich hätte die Beschwerdegegnerin auf Basis dieser Prognose zum Schluss kommen müssen, dass die erkennungsdienstliche Behandlung nicht erforderlich war.

Daher hat die Beschwerdegegnerin die personenbezogenen Daten des Beschwerdeführers unrechtmäßig verarbeitet.

Daher war spruchgemäß zu entscheiden.

Da die Beschwerdegegnerin, wie festgestellt, die gegenständlichen Daten des Beschwerdeführers gelöscht hat, war kein Leistungsauftrag zur erteilen.